

1504901-60.2022.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sandro Nogueira de Barros Leite

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... de venda de droga) com o fito de combater o tráfico de droga, eis que haviam denúncias de tráfico de entorpecente naquele local. Foi promovida atividade de campanha nas imediações, utilizando viatura descaracterizada, sendo visualizado a presença do investigado André Henrique Conceição da Silva e do adolescente infrator Júlio Cesar Vinicius Garisto Junior os quais estavam ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504901-60.2022.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504901-60.2022.8.26.0132

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2198340/2022 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2198340 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRÉ HENRIQUE CONCEIÇÃO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sandro Nogueira de Barros Leite

Vistos.

ANDRÉ HENRIQUE CONCEIÇÃO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06. Consta na denúncia que no dia 21 de julho de 2022, por volta de 11h20, na Rua das Maças, 274, Jardim Imperial, nesta cidade e Comarca de Catanduva/SP, o acusado, previamente ajustado com o adolescente Júlio Cesar Vinicius Garisto Júnior, guardava drogas, consistentes em 17 (dezesete) invólucros de "maconha" e 48 (quarenta e oito) pinos de "crack", para fins de comércio ilícito com terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de exame químico toxicológico (fls. 51/53).

A exposição do fato criminoso e suas circunstâncias estão assim descritos na denúncia:

Segundo apurado, policiais civis receberam informações sobre a prática de tráfico

de drogas no bairro, conhecido pela intensa comercialização ilícita, e foram até o local, utilizando viatura descaracterizada. Em observação à movimentação de pessoas pelo local, avistaram o indiciado, acompanhado do adolescente Júlio, promovendo a traficância da maneira como lhes fora informada. A dinâmica do comércio consistia na atuação do adolescente como vendedor, negociando com os usuários e repassando os pedidos ao indiciado, que retirava as porções de drogas do interior de um cano de água. Em revista pessoal, nada foi localizado, mas, durante diligências pelo local, foram encontrados, no interior de um cano, 17 (dezesete) invólucros de "maconha" e 48 (quarenta e oito) pinos de "crack". Indagados, ambos confessaram informalmente a traficância. As circunstâncias da apreensão, a quantidade e a forma de acondicionamento das substâncias, as informações recebidas pelos policiais e a observação que eles fizeram da dinâmica dos fatos, tudo denota que a prática do comércio ilícito.

Convertida prisão preventiva em liberdade provisória (fls. 54/57).

A denúncia (fls. 55/57) recebida em 19 de setembro de 2022 (fl. 75/76).

Houve defesa prévia (fls. 63/67).

Foi designada audiência de instrução e julgamento (fl. 75/76).

No curso da instrução processual foram ouvidas as testemunhas e interrogado o acusado.

Por ocasião do momento processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram.

Nas alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia.

A defesa destacou a primariedade do acusado. Requer, assim, aplicação do tráfico privilegiado e concessão de benefícios.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Processo em ordem, que se desenvolveu em conformidade com o princípio do contraditório e da ampla defesa. Inexiste nulidade a ser reconhecida ou irregularidade para sanar.

A denúncia foi regularmente instruída com os seguintes elementos informativos:

A testemunha E. H. S. R. (fl. 03) declarou: Informa que Policiais Civis desta Delegacia de Polícia Especializada dirigiram-se até a Rua das Maças, numeral 274 no bairro Jardim Imperial (conhecido ponto de venda de droga) com o fito de combater o tráfico de droga, eis que haviam denúncias de tráfico de entorpecente naquele local. Foi promovida atividade de campana nas imediações, utilizando viatura descaracterizada, sendo visualizado a presença do investigado André Henrique Conceição da Silva e do adolescente infrator Júlio Cesar Vinicius Garisto Junior os quais estavam comercializando entorpecente no local do fato, consistente na ação em que o adolescente verbalizava com os usuários e na sequência solicitava para André a droga, o qual retirava do interior de um cano de água 02 buchas e entregava o entorpecente para Júlio servir para o dependente químico, sendo então decidida pela abordagem policial. O policial Adolfo promoveu revista pessoal no autuado e no adolescente infrator, sendo que nada de ilícito foi encontrado com ambos, onde na sequência o policial Adolfo promoveu varredura no local do fato e apreendeu as 02 buchas que estavam no interior do cano de água, as quais acondicionavam respectivamente 17 invólucros plásticos de maconha e 48 pinos de crack.

Entrevistados, o investigado e o adolescente infrator informalmente revelaram a traficância. Ante o exposto, foi emanada voz de prisão a André Henrique Conceição da Silva e apreensão para Júlio Cesar Vinicius Garisto Junior e citados seus direitos constitucionais.

A testemunha A. H. (fl. 04) declarou: Acompanhava o Policial Civil Eduardo em diligências ao combate ao tráfico de droga, quando abordaram André Henrique Conceição da Silva e o adolescente infrator Júlio Cesar Vinicius Garisto Junior que estavam praticando a traficância no local do fato. O depoente em revista pessoal no investigado e no adolescente infrator nada de irregular foi localizado com ambos, tendo na sequência realizado varredura no local e apreendido as 02 buchas que estavam no interior do cano de água, as quais acondicionavam respectivamente 17 invólucros plásticos de maconha e 48 pinos de crack.

A testemunha menor J. C. V. G. G. (fl. 05) declarou: Não possui Advogado e não

indica nenhum deles para este ato. Sua prisão foi comunicada a seu padrasto que se fez presente nesta Especializada prestando-lhe assistência. Quanto aos fatos, abre mão do seu direito de permanecer calado para informar que é usuário de maconha e que na data de hoje foi comprar maconha no bairro Jardim Imperial ocasião em que foi abordado por policiais civis. Informa que é conhecido da pessoa de André Henrique Conceição da Silva. Declara não possuir envolvimento com o tráfico de droga. Notícia que em seu poder foi localizado apenas 02 porções de maconha. Interrogado, A. H. C. D. S. (fl. 06) declarou: Não possui Advogado e não indica nenhum deles para este ato. Sua prisão foi comunicada a sua genitora que se fez presente nesta Especializada prestando-lhe assistência. Quanto aos fatos, abre mão do seu direito de permanecer calado para informar que é usuário de droga e que na data de hoje foi comprar droga no bairro Jardim Imperial quando foi abordado por policiais civis. Esclarece que conhece de vista o adolescente Júlio Cesar Vinicius Garisto Junior. Não possui envolvimento com o tráfico de droga. Alega finalmente que foi localizado em seu poder somente uma pequena porção de maconha. Mediante análise jurídica concreta, baseada nos elementos de provas até então existentes, a denúncia foi recebida.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl.s 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 13), pelo laudo de constatação (fls. 15/17), pelo exame químico toxicológico (fls. 44/46) e por todos os demais elementos informativos e probatórios carreados nos autos.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado, não pairando qualquer dúvida a indicar situação diversa.

A busca pessoal exige fundada suspeita. O RHC 158580 / BA é bem ilustrativo:

“Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência”.

A excepcionalidade da conduta policial está fincada na justa causa, em especial pela necessidade de imediata cessação da conduta criminosa.

Observa-se que a busca pessoal não se aperfeiçoou apenas e tão somente em razão do tirocinio policial, mas também porque a conduta do acusado era suspeita, na medida em que estava em local cujo tráfico é corrente, acompanhado de um adolescente, ambos em franca atitude de comércio com terceiro, dependente químico. Apesar de na revista pessoal não ser nada encontrado, na verificação pelo local onde se encontrava, veio a confirmar conter quantidade de entorpecente, o que justificou a medida.

De se concluir, assim, que não se tratou de medida ilegal e abusiva, sob o nefasto pretexto de averiguação discriminatória, motivo pelo qual se afasta a tese da ilegalidade.

No mais, houve a produção de prova em juízo.

A testemunha E. H. S. R, policial civil, disse que estavam com viatura descaracterizada e conseguiram flagrar Júlio César, que fazia uso de uma bicicleta e André estava à pé. Viram que a droga estava sendo guardada no cano de água de uma casa por André. Perceberam na movimentação do tráfico que Julio César fazia comunicação com usuários e falava com André, que pegava as drogas, passava para Julio César ou ia ele mesmo e pegava o dinheiro. Nesse mesmo tempo, foram até uma padaria e voltaram ao local inicial. Eles disseram que não tinha nada a ver, mas viram toda a dinâmica. Deu para ver que estavam atuando em conjunto. Visualizou o ocorrido, mas foi outra equipe que fez a abordagem.

A testemunha A. H, policial civil, disse que o policial Eduardo fazia a campanha com viatura descaracterizada e passou as coordenadas do adolescente e do réu em ato de comércio de entorpecentes. Passadas as coordenadas, encontrou o entorpecente. Informalmente, disseram que estavam revezando o tráfico, estando os dois juntos. Disse que não pode afirmar se o réu é conhecido dos meios policiais vez que a

investigação não era sua.

O acusado A. H. C. D. S. disse que estava trabalhando numa lanchonete, mas o movimento estava fraco e foi dispensado. Não tinha dinheiro para pagar aluguel e pensão e estava desesperado e passou a vender droga. Quer ter uma oportunidade. Estava trabalhando, tranquilo. O menor não estava vendendo. O conhece da lanchonete. Está muito arrependido.

O acervo probatório produzido nos autos, especialmente ante os depoimentos das testemunhas policiais e das circunstâncias em que ocorreram os fatos são suficientes para o decreto condenatório.

Nesse ponto, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/11/2021).

Além da unicidade, firmeza e coerência da versão apresentada, todo arcabouço fático foi detalhado, retirando qualquer dúvida quanto à credibilidade dos seus depoimentos.

Em breve síntese, a versão dos policiais é uníssona e apontou que o acusado, acompanhado de um adolescente, encontrava-se em ponto de traficância corrente tendo sido avistado em atitude suspeita de comércio. Ao ser abordado, nada foi constatado com ambos. Contudo, realizado a varredura no local, foi localizado e apreendido 02 "buchas" que estavam no interior do cano de água, as quais continham: - 17 invólucros plásticos de maconha e 48 pinos de crack.

A prova oral ainda confirmou a dinâmica operada entre o acusado e o menor dando conta que o adolescente associado ao réu oferecia e entregava a consumo entorpecentes, enquanto o réu guardava as drogas em um cano de água.

Em juízo, o próprio réu, apesar de negar a colaboração com o adolescente, confirmou que estava no local em que fora abordado praticando o comércio ilícito de entorpecente.

Nesse ponto da presença do adolescente, de se ver que a versão do acusado restou isolada nos autos, destacando-se, sobretudo, que ambos os policiais militares foram taxativos em afirmar que o menor e o réu estavam atuando em conjunto.

Vale destacar que quanto ao artigo art. 40, VI, da Lei 11.343/06: "Aplica-se a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06 sempre que criança, adolescente, ou quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação figurar como vítima do delito ou como coautor ou partícipe. Justifica-se o recrudesimento pela maior vulnerabilidade desses indivíduos, suscetíveis ao consumo de entorpecentes ou à cooptação para o exercício do comércio malsão, tendo em vista a reduzida capacidade de discernimento, a inimizabilidade e a particular condição biológica, psíquica, moral e de caráter, ainda em fase prefacial de formação." (HC n. 411.340/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 26/2/2018).

Veja que o tipo em comento destaca os verbos envolver ou visar a atingir criança ou adolescente, independentemente de anterior corrupção do menor, visto que se a intenção for esta, estar-se-ia diante do tipo descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, cujos verbos são corromper ou facilitar a corrupção.

Para ilustrar: "Para a configuração da causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, não importa se o adolescente envolvido na prática da mercancia ilícita não era neófito no mundo do crime". (AgRg no HC 739533 / SP).

Como a descrição típica é claramente formal, basta a participação da criança ou do adolescente para a sua incidência, o que restou demonstrado nos autos.

Demais disso, "A figura de transportar, trazer consigo, guardar ou, ainda, adquirir não exige, para a adequação típica, qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou comercializar. O tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, este sim, como delictum sui generis, apresenta a estrutura de congruente assimétrico ou incongruente, visto que o seu tipo subjetivo, além do dolo, exige a finalidade do exclusivo uso próprio" (REsp n. 1.134.610/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2010)

A quantidade de droga, sua variedade e forma de acondicionamento não denotam a

finalidade de mero consumo próprio, especialmente porque encontrado em seu poder entorpecente fracionado e embalado, certo ainda que não fora apreendido qualquer petrecho compatível com o consumo da referida substância.

Acrescente-se que o acusado confessou a autoria delitiva, afirmando que estava traficando por questão financeira.

Conclui-se, assim, que a prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

DA APLICAÇÃO DA PENA.

Escorado no art. 68 do CP, a pena será individualizada em três fases distintas.

Parte-se das circunstâncias judiciais.

A culpabilidade consubstanciada na reprovação social da sua conduta não está acima da média. Ostenta bons antecedentes (fls. 30). A conduta social não restou demonstrada nos autos. Não há certeza se a sua personalidade aponta para a prática de crimes. O motivo do crime é reprovável, mas próprio do tipo. As circunstâncias do crime também são normais ao tipo legal. Não houve consequências do crime, traduzido como aquele que se revela além do resultado natural. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento da infração.

A quantidade de entorpecente apreendido é o bastante para a configuração do delito, mas não para a majoração da pena.

Em assim sendo, e por considerar as circunstâncias judiciais preponderantemente favoráveis ao réu, fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, em 05 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, analisa-se as atenuantes e as agravantes expressamente previstas em lei, cuja incidência não conduz à diminuição da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231) e por simetria e proporcionalidade, acima do máximo legal.

No caso em apreço, presente a atenuante prevista no art. 65, I do CP, bem como a da confissão espontânea e ausente a agravante. Mas a pena base já foi fixada no seu valor mínimo.

Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mínimo legal de 05 anos de reclusão.

Por fim, examina-se as causas de diminuição e de aumento da pena.

Ausente causa de diminuição, mas presente a causa de aumento de pena prevista no inciso VI do art. 40 da lei nº 11.343/06.

Desta forma, fixo a pena na terceira fase em 05 anos e 10 meses de reclusão.

Inaplicável o disposto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, visto que não preenche os requisitos legais. Leva-se em conta o entendimento do STJ que "o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas" (HC n. 435.685/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 11/4/2018).

A vida pregressa do acusado está recheada de envolvimento com a criminalidade, em especial o tráfico ilícito de entorpecente (fls. 30). Nascido em 08 de outubro de 2003, atingiu a maioridade penal em 08 de outubro de 2021.

Este processo é de 2022. Observa-se que desde 2019 está envolvido com o tráfico ilícito de entorpecente, o que deixa evidente ser o seu meio de vida, criando obstáculo à concessão do tráfico privilegiado.

Desse modo, torno-a definitiva em 05 anos e 10 meses de reclusão.

Já a pena pecuniária é fixada adotando-se o sistema bifásico.

Sabe-se que "Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu." (REsp 1535956/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

As circunstâncias judiciais são preponderantemente favoráveis ao acusado, motivo pelo qual a multa é fixada no mínimo legal, ou seja, 500 dias-multa.

No mais, não há provas da capacidade econômica do réu, o que enseja a fixação do dia-multa no valor de um trigésimo do salário-mínimo legal vigente ao tempo dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, diante do teor do art.

33, §2º, 'c', do CP.

Tal cenário não resta alterado com a aplicação do disposto no art. 387, §2º, do CPP.

Da substituição da pena: medida de política criminal visando a aplicação de sanção sem retirar o indivíduo do convívio social, desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 44 do Código Penal, cumulativamente. A pena aplicada é superior a 4 anos, o que inibe a substituição, sendo desnecessária a análise das demais condições cumulativas.

Também não é caso de suspensão condicional da pena, vez que não preenchidos os requisitos legais, no caso, a pena aplicada é superior a 2 anos (CP, art. 77, caput).

Por tais considerações, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o acusado ANDRE HENRIQUE CONCEIÇÃO DA SILVA, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo vigente à época do fato.

Por se tratar de crime vago, não há se falar em fixação de valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Fls. 96/97: defiro o pedido de justiça gratuita ao réu. Anote-se.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da aplicação analógica do art. 98, §3º, do CPC c.c art. 3º do CPP.

Ante o regime inicial fixado e à luz do princípio da homogeneidade, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, §1º, do CPP). Expeça-se alvará de soltura.

Em observância ao art. 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das amostras de substância entorpecente guardadas para contraprova, com certificação nos autos.

Com base no art. 63, I, da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do numerário apreendido nos autos (arts. 63-C e 63-D da Lei 11.343/06).

Proceda-se às comunicações de praxe, e com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, III, da CF.

Publique-se. Intimem-se, com observância do disposto no art. 392 do CPP.

Catanduva, 14 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA